

1500088-21.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado.

4. Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, não há óbice à incidência da minorante do tráfico privilegiado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500088-21.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500088-21.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2015819/2021 - DEL.POL.PLANTÃO PINDA, 15739200 - DEL.POL.PLANTÃO PINDA, 104/21/517 - DEL.POL.PLANTÃO PINDA, 2015819 - DEL.POL.PLANTÃO PINDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAZARO JOSE BENEDITO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia porque, segundo consta, a partir de data incerta e até o dia 18 de janeiro de 2021, em ocasião de calamidade pública, nesta região do Vale do Paraíba, LÁZARO JOSÉ BENEDITO, FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, MARCOS HENRIQUE DE MEDEIROS CORREA, qualificado a fls. 13, e ELTON WILLIAM MOREIRA, todos qualificados nos autos, associaram-se entre si e ao adolescente L.G.R.A., com 16 anos de idade ao tempo do fato, para o fim de praticar os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta, ainda, que no dia 18 de janeiro de 2021, até por volta das 18 horas, em ocasião de calamidade pública, na Av. Carlos Lopes Guedes Filho, nas proximidades do nº 1.000, e em outras vias públicas, Bem Viver, Araretama, neste município,

LÁZARO JOSÉ BENEDITO, FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, MARCOS HENRIQUE DE MEDEIROS CORREA e ELTON WILLIAM MOREIRA, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de propósitos entre si e com o adolescente L.G.R.A., após terem adquirido, tinham em depósito, guardavam e transportavam – a bordo do veículo VW Fox, cinza, placas EYU 2301 –Taubaté/SP, para entregar e fornecer a consumo de terceiros, 4.843,9 gramas de Cannabis sativa l., popularmente conhecida como “maconha”, contendo tetraidrocanabinol, e 200,31 gramas de cocaína, drogas aptas a causar dependência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo narra o Parquet, LÁZARO, FLÁVIO HENRIQUE, MARCOS HENRIQUE e ELTON se associaram entre si e ao adolescente L.G.R.A. com a finalidade de traficar drogas, especialmente para a aquisição, guarda, depósito, transporte, venda e entrega a consumo de terceiros de maconha e de cocaína. Assim associados, os denunciados e o adolescente adquiriram 4.843,9 gramas de “maconha e 200,31 gramas de cocaína; em seguida, passaram a guardar, ter em depósito e transportar, a bordo do veículo automotor VW/Fox (conduzido por LÁZARO), aquelas drogas, para posterior fornecimento e venda a terceiros.

Ante o exposto, LÁZARO JOSÉ BENEDITO, FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, MARCOS HENRIQUE DE MEDEIROS CORREA e ELTON WILLIAM MOREIRA foram denunciados como incursos nos artigos 35, caput, e 33, caput, ambos c.c. o artigo 40, inciso VI (envolver adolescente), todos da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), observadas as disposições da Lei 8.072/90, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea j (em ocasião de calamidade pública), do Código Penal.

Em sede de audiência de custódia, realizada em 19 de janeiro de 2021, a prisão em flagrante dos indiciados foi convertida em preventiva (fls. 129/138).

Os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 244/252 e 303/304), ocasião em que o acusado LÁZARO pugnou pela rejeição da denúncia e os demais corréus se reservaram o direito de apresentar seus argumentos em momento processual oportuno.

Afastada a preliminar arguida pelo corréu LÁZARO, a denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2022 (fls. 369/371).

Em sede de audiência de instrução e julgamento realizada de forma virtual, pela Plataforma Teams, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, interrogados os acusados.

O Ministério Público, em alegações finais apresentadas de forma, pugnou pela parcial procedência da pretensão punitiva estatal, com a absolvição do corréu LÁZARO e condenação dos demais acusados.

A Defesa de LÁZARO JOSÉ BENEDITO, em alegações finais apresentadas por memoriais (fls. 431/438), sustentou a absolvição por falta de provas; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e o regime inicial aberto de cumprimento de pena.

A Defesa dos demais corréus, em alegações finais apresentadas por memoriais (fls. 439/444), pugnou pela parcial procedência da denúncia, tão somente para a condenação do corréu FLÁVIO HENRIQUE em relação ao delito do art. 33 da Lei de Droga, com o afastamento de todas as demais imputações pela fragilidade probatória. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Não há questões preliminares ou prejudiciais que possam ser dirimidas. Passo, desde logo, ao exame do mérito.

Os pedidos formulados na exordial acusatória são parcialmente procedentes.

O crime de tráfico de drogas está assim previsto:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Da leitura do dispositivo apontado, depreende-se que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria e a responsabilidade criminal dos denunciados, momento em que se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto pelo artigo

52, I, da Lei 11.343/06, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: a) natureza e quantidade da substância apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstâncias da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente.

Os vários núcleos verbais constantes do artigo 33 da Lei de Drogas fazem dele um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Assim, mesmo que o agente pratique, em um mesmo contexto fático, mais de uma ação típica, responderá por crime único, haja vista o princípio da alternatividade.

Pois bem.

Considerando que a pretensão punitiva do Estado pressupõe a conjugação dos elementos materialidade e autoria, os reputo presentes no caso em análise, com exceção do réu Lázaro, cuja absolvição é medida impositiva.

A materialidade vem corroborada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 07/08; laudo de constatação preliminar de fls. 45/48 (que demonstra a apreensão de 200,31g de cocaína e 4843,9g de Tetrahidrocannabinol (THC)); laudo definitivo de fls. 265/267, certidão de nascimento do menor L.G, atestando sua menoridade à época dos fatos; e demais provas amealhadas durante a instrução processual.

No tocante às autorias, a prova oral foi colhida no seguinte sentido:

A testemunha Jefferson Santos de Paula, policial militar, relatou que estavam fazendo patrulha pelo Condomínio Bem viver, Pindamonhangaba, quando se depararam com veículo Fox, com 5 ocupantes, em atitude suspeita, que após abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles, que somente foi encontrado com o menor Luiz Guilherme a quantia de R\$ 60,00, que feita a busca no porta malas do veículo foram encontradas 2 mochilas, cheias de drogas e aparelhos celulares, que uma das mochilas o menor falou ser dele, falou também ser de jacarei e que recebeu R\$ 50,00 para trazer a mochila para Pindamonhangaba, que foi lhe entregue na praça de pedágio por uma pessoa de moto, que não soube informar quem era, e que o veículo fox iria pegá-lo no pedágio e leva-lo até Pindamonhangaba, que quando chegaram no Condomínio Bem viver e Salgueiro, pegaram mais 3 indivíduos, porém não soube informar qual dos três estava com a mochila, ainda questionado, informou que teria de levar a mochila para um local que não conhecia, mas que o motorista iria conduzi-los; que a outra mochila ninguém assumiu a propriedade. Relatou ainda, que o motorista Lázaro informou que recebia um valor mensal de R\$ 500,00 para levar umas pessoas na parte da tarde e trazê-las de manhã, do Condomínio Bem viver até Tremembé, que não soube informar o local nem informações da pessoa que o contratou; os outros três ocupantes informaram que estavam indo para um sítio em Tremembé a trabalho, à noite toda e que retornariam de manhã. Apuraram, ainda na revista que as mochilas continham grande quantidade de maconha, cocaína, vários aparelhos de celular, carregadores de celular, fones de ouvido, baralho e maço de cigarro, estavam em vários pacotes, sendo que cada, continha anotação referindo-se à raías de presídio, que ainda na busca veicular foram encontrados mais 3 celulares e dinheiro no valor de R\$ 220,00, sendo que Lázaro falou ser dele 1 celular e o dinheiro, que após, foi dado voz de prisão e conduzidos ao DP.

A testemunha José Ricardo Moreira, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento no Bairro Bem viver quando se depararam com o veículo fox, com ocupantes nervosos e agitados, e que por isso decidiram fazer abordagem ao veículo, que feita revista e busca pessoal, com eles nada de ilícito foi localizado, mas que no porta malas foram encontradas 2 mochilas, contendo grande quantidade de entorpecentes, aparelhos celulares, fones de ouvido, carregadores, cigarro e baralho, que indagados sobre a propriedade das mochilas, somente o menor assumiu ser dono de uma delas, informou o adolescente que é de jacarei, que recebeu a quantia de R\$ 50,00 para trazer a mochila para pinda, que o veículo fox iria pegá-lo na praça do pedágio, que a mochila lhe foi entregue por um motoqueiro desconhecido, que embarcou no fox e quando chegaram no Condomínio Bem viver e condomínio Salgueiro, mais 3 pessoas entraram no veículo e que não sabe dizer quem colocou a mochila no porta malas, indagado a respeito, o motorista informou que recebeu uma quantia para levar esse pessoal do Condomínio bem viver até esse sítio na cidade de Tremembé, que leva todo final de tarde e vai busca-los no outro dia

de manhã, que não sabe o que fazem lá, nem informar quem o contratou, que os outros ocupantes ao serem questionados, informaram que iriam a esse sítio para trabalhar à noite inteira, que lá tem criação de gado, que sobre a outra mochila nenhum deles assumiu a propriedade e ainda tentaram responsabilizar o adolescente por ela, que negou, assumindo que somente trouxe uma.

Quanto às oitivas dos policiais militares, estas corroboram os fatos descritos na denúncia, merecendo a devida credibilidade, sobretudo porque não há nos autos quaisquer motivos válidos para se suspeitar da parcialidade dos agentes. Desse modo, salvo na hipótese de se comprovar animosidades pregressas ou interesse na sentença penal condenatória, os depoimentos dos policiais devem ser revestidos do devido valor probatório, principalmente porque seus atos gozam de presunção de legitimidade e agem em estrito cumprimento do dever legal.

Sob esse aspecto, denoto que os depoimentos dos policiais colacionados nos autos são coerentes e harmônicos entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, razão pela qual, à míngua de qualquer alegação de suspeita, encontram-se revestidos de lastro suficiente para embasar o decreto condenatório.

Os réus, advertidos do direito ao silêncio, apresentaram suas versões dos fatos:

O réu Lázaro José Benedito relatou que é eletricitista e trabalha com uber, que recebeu uma ligação na parte da manhã para fazer uma corrida às 5h da tarde, disse que tudo bem e continuou trabalhando, e que às 4:30h recebeu mais uma ligação pedindo para fazer uma corrida, falou que não, porque tinha uma corrida próxima, porém iria para o mesmo local e indagou se poderia ir também. Às 5h pegou o Flávio que entrou com a mochila, que pediu para pôr no porta-malas, que pegou outro passageiro no ponto de ônibus no Condomínio Bem viver, para fazer a mesma corrida no valor de R\$ 20,00, que não foi chamado por aplicativo, que ligaram para ele, pois faz corridas fora do aplicativo também, para complementar sua renda, para ajudar a família de sua esposa, pois seu pai estava com câncer. Relatou ainda que não os conhecia e que não sabia o que tinha nas mochilas. Às 5h da tarde pegou Flávio, depois o menor e que outros dois passageiros entraram depois, pelo caminho, não estavam juntos, mas sem mochila, que não estavam juntos, que foram pegos no caminho, que seu celular é um LG K10 e que recebeu 3 ligações.

O réu Elton Willian Moreira relatou que no dia dos fatos, por volta das 4:30h, ligou para o rapaz do fox, pedindo para que ele o levasse para Tremembé, bairro Berizal para ver um serviço, que combinaram a corrida às 5h pois já tinha uma corrida combinada no condomínio bem viver, que por volta das 5:10h o pegou no condomínio Salgueiro, e que no carro se encontravam ele e mais 3 rapazes no carro, e que ao saírem se depararam com a patrulha rocam da Polícia Militar, que foram abordados e que foi perguntado ao dono do veículo se tinha alguma coisa ilícita dentro do carro, sendo dito que não, que feita a vistoria nada foi encontrado dentro do carro, porém dentro do porta malas foram encontradas 2 mochilas, e que perguntado de quem eram, um rapaz falou que uma bolsa era dele, a outra ninguém assumiu, que elton perguntou ao motorista de quem era a bolsa, pois ele tinha entrado no carro sem, porém o motorista não respondeu, e que após foram levados para a delegacia. Afirmou ainda que ao entrar no carro já havia outras 3 pessoas, o Marcos, o Flávio e o adolescente, que não os conhecia e que tinha o número do contato do Lázaro de um ponto de ônibus do Bem viver, que já tinha passagem por tráfico em 2005-2006 e outras passagens por roubo e uma de arma, que saiu em 24 de julho da penitenciária, que estava assinando, e que estava trabalhando.

O réu Marcos Henrique de Medeiros, afirmou que estava no ponto de ônibus quando veio o carro do Lázaro e parou perguntando para onde estava indo, que respondeu que estava indo para Tremembé, que o motorista perguntou se ele queria ir junto pois estava indo para lá também, que aceitou e que dentro do veículo já se encontravam 2 pessoas e que só faltava um para completar a corrida, que sempre fazia corrida no Bem viver, falou também que iria passar no condomínio salgueiro para pegar um rapaz, o Elton, que ao saírem do Salgueiro, encontraram com 3 motocicletas da rocam da polícia militar, que pararam do lado deles, que ao serem abordados e feita vistoria dentro do carro, nada foi encontrado de ilícito, porém, dentro do porta malas foram encontradas duas bolsas, que um rapaz falou ser dono de uma, e quanto à outra ninguém assumiu e que após, foram todos para a delegacia. Afirmou ainda que

não sabia se quem assumiu a mochila era menor, pois não o conhecia e que não conhecia os demais passageiros, que tem passagem por tráfico e roubo e que há três anos solto sem problemas com a justiça, falou estava indo para a rodoviária de Tremembé.

O réu Flávio Henrique dos Santos Silva, narrou que a bolsa com as drogas era dele, que recebeu uma proposta de uma pessoa chamada Michel que mora no bairro bem viver, que iria dar a ele R\$ 500,00 para levar a bolsa e mais um rapaz, que viria de Pindamonhangaba até Tremembé, e que como estava desempregado aceitou a proposta, para levar a bolsa até Tremembé onde iria ter uma menina ruiva o esperando no ponto de motoboy, na entrada do viaduto; que ele e o rapaz de Jacareí chegaram por volta das 3h, que ligou para o Lázaro os apanhar, que colocou a bolsa no porta malas e, após, seguiram viagem, que sua sogra mora no condomínio cerejeira, que reside no bairro do Mombaça com sua mãe, que quando estavam subindo o bem viver, viu um rapaz, que o motorista perguntou para onde estava indo, sendo que o rapaz falou que estava indo para Tremembé e aceitou ir junto, que o motorista falou que só tinha de pegar um passageiro no Salgueiro e que quando estavam saindo de lá, chegaram as 3 motos da Rocam, e pararam no lado do carro, foi quando ficou com medo e ficou se mexendo de um lado para outro dentro do carro, que os policiais conversavam entre eles e o carro foi indo, foi quando as motos vieram atrás e pararam o carro, falou que a droga não era dele, mas que estava sob sua responsabilidade, que iria transportar essa outra mochila e deixar este outro rapaz em Tremembé. Informou ainda, que estava respondendo por um homicídio, por causa de uma ex-namorada, que ficou preso por 1 ano e um mês e saiu. que rapaz que pegou era menor, mas que não sabia quem era, porque não o conhecia, que mudou a versão que deu na Delegacia porque ficou com medo, pois tem uma filha pequena com 5 meses, que estavam passando por necessidade e que por isso aceitou essa proposta e que quando a polícia os parou ficou com medo de assumir a droga, mas que perante o juízo está falando a verdade, pois está preso há 1 ano e 3 meses, longe de sua família. Lázaro não sabia o que estava nas bolsas e nem os outros rapazes. Que chegou e o menor e outro rapaz já estavam no condomínio Cerejeira, após uma hora e pouco chegou o Lázaro e os pegou, e colocou a bolsa que estava com ele e a que estava com o rapaz no porta-malas.

Não obstante a confissão do réu Flávio, as versões apresentadas pelos demais corréus, com exceção de Lázaro, restam isoladas nos autos, com evidente tentativa de infirmar a responsabilidade criminal dos réus reincidentes.

Ademais, verifico que as versões apresentadas em sede policial conflitam com as narradas em juízo. Conforme se depreende de fl. 17, o réu Flávio narrou à Autoridade Policial que chamou o uber (Lázaro) para que o levasse junto com mais dois vizinhos do bairro "bem viver" até a cidade de Tremembé, pois iriam à casa de um amigo "tomar cerveja".

Em juízo, ao contrário do que fora narrado àquela oportunidade, aduziu não conhecer os demais corréus, narrando somente que entrara no carro com o adolescente, cuja menoridade desconhecia.

Portanto, o que se extrai dos elementos informativos colhidos em fase policial, quando confrontados com as provas amealhadas em fase instrutória, autorizam o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade "trazer consigo".

Ressalto que se cuida, conforme delineado supra, de tipo misto alternativo, sendo prescindível qualquer ato de mercancia para a consumação do crime, bastando que o agente incida em quaisquer dos verbos nucleares. Anote-se:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.CONFIGURAÇÃO.

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRADIÇÃO DO ENTORPECENTE. O

aperfeiçoamento do crime de tráfico de entorpecentes não exige a efetiva tradição da droga, sendo igualmente inexigível a comprovação da mercancia. In casu, resta devidamente demonstrada a participação do acusado na trama delituosa, o que torna imperiosa a sua condenação. Recurso conhecido, mas desprovido."(STJ, REsp 623589 / SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. FIM DE AGIR. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE USO PRÓPRIO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio (REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010). 2. Na hipótese, as instâncias originárias concluíram que o entorpecente apreendido - 1.473 g de haxixe - não se destinava exclusivamente ao consumo próprio do paciente. Inviável, nesta via, para afastar tal conclusão, o reexame do material fático-probatório produzido. 3. Ordem denegada."(HC 629.670/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 23/03/2021, grifei) (grifei e negritei).

Em detida análise dos autos, observa-se que o contexto em que efetuadas as prisões, aliado à expressiva quantidade e variedade de drogas não permitem conclusão diversa se não a incidência do art. 33, da Lei 11.343/06; e isso porque "para se concluir pela prática do crime de tráfico (e outras tipificações da Lei de drogas), não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In ELTASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

No tocante à causa de aumento de pena relativa ao art. 40, VI, da Lei de Drogas (a prática do dos crimes dos arts. 33 a 37 da Lei de drogas envolverem ou visarem a menores de dezoito anos), de igual forma, é de rigor o reconhecimento.

O verbo "envolver", em novidade legislativa, demanda, segundo Renato Brasileiro de Lima (2022, p. 1312) colaboração de menor ou de incapaz no tráfico, tornando-se um comparsa do traficante, ainda que de maneira eventual. Esse verbo apresenta conduta material, cujo resultado naturalístico é obtido a partir da participação do menor em quaisquer núcleos dos arts. 33 ao 37, da Lei de Drogas, o que é o caso dos presentes autos.

Superada a análise quanto à condenação pelo crime de tráfico, verifico que raciocínio diverso deve ser aplicado quanto ao delito do art. 35 da mesma Lei, tendo em vista que não há nos autos quaisquer elementos quanto ao animus associativo, aplicando-se a normativa do art. 29, caput, do Código Penal (concurso de agentes).

O crime de associação para o tráfico, não obstante classificado pela doutrina como crime "formal" ou "de perigo", demanda os elementos estabilidade e permanência do vínculo associativo, de forma que devem ser colacionados nos autos lastros probatórios que afastem a hipótese de mero concurso de pessoas. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA.

1. Os dizeres do acórdão, com referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os réus, não se afiguram suficientes para embasar e condenação nesse ponto da imputação.

2. O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

3. É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado.

4. Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, não há óbice à incidência da minorante do tráfico privilegiado. "No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser

utilizadas em duas fases da dosimetria da pena. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base"(AgRg no HC 704.313/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

5. Provimento do recurso especial. Absolvição dos recorrentes da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006 e art. 386, VII - CPP). Incidência da minorante do tráfico privilegiado, resultando a pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 200 dias-multa pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

(REsp 1978266/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022). (grifei e negritei). Diante disto, uma vez que não colacionadas quaisquer provas nesse sentido, a absolvição do crime de associação para o tráfico é medida impositiva a todos os réus.

DOSIMETRIAS:

Com base no art. 68, do Código Penal, observando o critério trifásico da dosimetria da pena, passo a analisá-las individualmente.

O crime de tráfico de drogas previsto no caput, do art. 33, da Lei 11.343/06 tem pena mínima de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase de dosimetria da pena, observa-se as circunstâncias judiciais constantes no art. 42, da Lei 11.343/06 e, em seguida, no art. 59, do Código Penal. Passo a dosar as penas.

Quanto ao réu FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS:

A natureza e quantidade das substâncias apreendidas ultrapassam a normalidade do delito. Cuidam-se de drogas com alto potencial lesivo (maconha e cocaína), além de quantidade exposta nos registros fotográficos e laudo de fls. 45/48 (que demonstra a apreensão de 200,31g de cocaína e 4843,9g de Tetrahydrocannabinol (THC)), justificando a valoração negativa desta circunstância.

A personalidade trata do caráter do agente, o que deve ser comprovado nos autos, em regra, mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, o que não há no presente caso.

A conduta social refere-se ao comportamento do réu perante a sociedade, nada tendo a se valorar.

A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime/contravenção e, no caso, é normal à espécie.

Os antecedentes tratam da vida pregressa e do envolvimento da agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, em que pese o réu esteja respondendo a outro processo criminal, esse fato não pode gerar valoração negativa em razão da ausência de trânsito em julgado, nos termos da súmula 444, do STJ.

Os motivos do crime constituem proveito econômico por meio da mercancia do entorpecente, compoendo a punição do próprio tipo, razão pela qual não pode ensejar qualquer espécie de valoração.

As circunstâncias do crime constituem o modus operandi do delito, que se apresentam normais à espécie no caso em tela.

As consequências do crime referem-se à extensão dos danos ocasionados pelo delito, os quais se revelam normais à espécie.

Tendo em vista que o tipo tutela a saúde pública, não há vítimas definidas, por isso, não há falar em comportamento da vítima.

Presente uma circunstância judicial desfavorável, na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 647642/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 15/06/2021.), exaspero a pena mínima em 1/6. Fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

Uma vez presente a atenuante da confissão, nos moldes da súmula 545, do STJ, reconheço sua incidência no caso concreto, retomando a pena base ao mínimo legal, não podendo ficar aquém nesta fase da dosimetria, conforme dicção da súmula 231, da

mesma Corte.

Fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa

Na terceira fase, presente a causa de aumento referente ao art. 40, VI, aumento a pena em 1/6- uma vez que não há nos autos elementos que justifiquem maior exasperação, somando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não é o caso de aplicação da minorante referente ao §4º, do art. 33, da Lei de drogas uma vez que natureza e quantidade do entorpecente (200,31g de cocaína e 4843,9g de Tetrahydrocannabinol (THC)) e o fato de envolver a presença de menor de idade, atestam o maior grau de periculosidade à conduta ora analisada, afastando o benefício.

Fixo a pena definitiva do réu FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em valor mínimo-unitário.

Deixo de aplicar a detração preconizada no artigo 387, §2º, do CPP e na súmula 716 do STF, para não invadir a seara de competência do juízo da execução, uma vez que o regime inicial não será modificado mesmo após o reconhecimento do instituto.

Impositiva a fixação do regime inicial SEMIABERTO para início do cumprimento da pena conforme art. 33, §2º, b, do CP, em razão do quantum da pena aplicada.

Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que além de a pena ter sido aplicada em patamar superior a quatro anos de reclusão, os antecedentes criminais do acusado não apontam que essa substituição seja suficiente à reprimenda do delito, afastando os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Igualmente, tendo em vista que o quantum da pena aplicada ao caso concreto ultrapassa dois anos, afastando a incidência do art. 77, do Código Penal.

Quanto ao tratamento dado à prisão preventiva, verifico que o réu respondeu à instrução processual custodiado e não há alterações de fato ou direito que justifiquem sua liberdade provisória. Assim, embasado no art. 312, do Código de Processo Penal, entendo estarem presentes os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar em vista à ordem pública.

Ressalto que a custódia cautelar deve observar o regime de cumprimento inicial, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao réu MARCOS HENRIQUE DE MEDEIROS CORREA:

A natureza e quantidade das substâncias apreendidas ultrapassam a normalidade do delito. Cuidam-se de drogas com alto potencial lesivo (maconha e cocaína), além de quantidade exposta nos registros fotográficos e laudo de fls. 45/48 (que demonstra a apreensão de 200,31g de cocaína e 4843,9g de Tetrahydrocannabinol (THC)), justificando a valoração negativa desta circunstância.

A personalidade trata do caráter do agente, o que deve ser comprovado nos autos, em regra, mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, o que não há no presente caso.

A conduta social refere-se ao comportamento do réu perante a sociedade, nada tendo a se valorar.

A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime/contravenção e, no caso, é normal à espécie.

Os antecedentes tratam da vida pregressa e do envolvimento da agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, ambas as condenações com trânsito em julgado do réu encontram-se no período depurador e serão valoradas na segunda fase da dosimetria, evitando-se o bis in idem (súmula 241, STJ).

Os motivos do crime constituem proveito econômico por meio da mercancia do entorpecente, compondo a punição do próprio tipo, razão pela qual não pode ensejar qualquer espécie de valoração.

As circunstâncias do crime constituem o modus operandi do delito, que se apresentam normais à espécie no caso em tela.

As consequências do crime referem-se à extensão dos danos ocasionados pelo delito, os quais se revelam normais à espécie.

Tendo em vista que o tipo tutela a saúde pública, não há vítimas definidas, por

isso, não há falar em comportamento da vítima.

Presente uma circunstância judicial desfavorável, na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 647642/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 15/06/2021.), exaspero a pena mínima em 1/6.

Fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fl. 92- autos nº 0001945.2016.8.26.0520 e 0005958-68.2015.8.26.0445), exaspero a pena em mais 1/5.

Não concorrem atenuantes.

Fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento referente ao art. 40, VI, aumento a pena em 1/6- uma vez que não há nos autos elementos que justifiquem maior exasperação, somando 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa.

Não é o caso de aplicação da minorante referente ao §4º, do art. 33, da Lei de drogas uma vez que natureza e quantidade do entorpecente (200,31g de cocaína e 4843,9g de Tetrahydrocannabinol (THC)) e o fato de envolver a presença de menor de idade, atestam o maior grau de periculosidade à conduta ora analisada, afastando o benefício.

Fixo a pena definitiva do réu MARCOS HENRIQUE DE MEDEIROS CORREA em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa em valor mínimo-unitário.

Deixo de aplicar a detração preconizada no artigo 387, §2º, do CPP e na súmula 716 do STF, para não invadir a seara de competência do juízo da execução, uma vez que o regime inicial não será modificado mesmo após o reconhecimento do instituto.

Impositiva a fixação do regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena conforme art. 33, §2º, a, do CP, em razão do quantum da pena aplicada, bem como de seus antecedentes criminais.

Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que além de a pena ter sido aplicada em patamar superior a quatro anos de reclusão, os antecedentes criminais do acusado não apontam que essa substituição seja suficiente à reprimenda do delito, afastando os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Igualmente, tendo em vista que o quantum da pena aplicada ao caso concreto ultrapassa dois anos, afastando a incidência do art. 77, do Código Penal.

Quanto ao tratamento dado à prisão preventiva, verifico que o réu respondeu à instrução processual custodiado e não há alterações de fato ou direito que justifiquem sua liberdade provisória. Assim, embasado no art. 312, do Código de Processo Penal, entendo estarem presentes os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar em vista à ordem pública.

Quanto ao réu ELTON WILLIAM MOREIRA:

A natureza e quantidade das substâncias apreendidas ultrapassam a normalidade do delito. Cuidam-se de drogas com alto potencial lesivo (maconha e cocaína), além de quantidade exposta nos registros fotográficos e laudo de fls. 45/48 (que demonstra a apreensão de 200,31g de cocaína e 4843,9g de Tetrahydrocannabinol (THC)), justificando a valoração negativa desta circunstância.

A personalidade trata do caráter do agente, o que deve ser comprovado nos autos, em regra, mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, o que não há no presente caso.

A conduta social refere-se ao comportamento do réu perante a sociedade, nada tendo a se valorar.

A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime/contravenção e, no caso, é normal à espécie.

Os antecedentes tratam da vida pregressa e do envolvimento da agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou (fl. 102), o réu possui anotação em sua folha de antecedentes cujo período depurador transcorreu, justificando a valoração negativa da circunstância.

Os motivos do crime constituem proveito econômico por meio da mercancia do

entorpecente, compondo a punição do próprio tipo, razão pela qual não pode ensejar qualquer espécie de valoração.

As circunstâncias do crime constituem o *modus operandi* do delito, que se apresentam normais à espécie no caso em tela.

As consequências do crime referem-se à extensão dos danos ocasionados pelo delito, os quais se revelam normais à espécie.

Tendo em vista que o tipo tutela a saúde pública, não há vítimas definidas, por isso, não há falar em comportamento da vítima.

Presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 647642/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 15/06/2021.), exaspero a pena mínima em 1/6 para cada uma delas.

Fixo a pena base em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fl. 101- autos nº 0004961-90.2012.8.26.0445), exaspero a pena em mais 1/6.

Não concorrem atenuantes.

Fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento referente ao art. 40, VI, aumento a pena em 1/6- uma vez que não há nos autos elementos que justifiquem maior exasperação, somando 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa.

Não é o caso de aplicação da minorante referente ao §4º, do art. 33, da Lei de drogas uma vez que natureza e quantidade do entorpecente (200,31g de cocaína e 4843,9g de Tetrahydrocannabinol (THC)) e o fato de envolver a presença de menor de idade, atestam o maior grau de periculosidade à conduta ora analisada, afastando o benefício.

Fixo a pena definitiva do réu ELTON WILLIAM MOREIRA em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa.

Deixo de aplicar a detração preconizada no artigo 387, §2º, do CPP e na súmula 716 do STF, para não invadir a seara de competência do juízo da execução, uma vez que o regime inicial não será modificado mesmo após o reconhecimento do instituto.

Impositiva a fixação do regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena conforme art. 33, §2º, a, do CP, em razão do quantum da pena aplicada, bem como de seus antecedentes criminais.

Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que além de a pena ter sido aplicada em patamar superior a quatro anos de reclusão, os antecedentes criminais do acusado não apontam que essa substituição seja suficiente à reprimenda do delito, afastando os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Igualmente, tendo em vista que o quantum da pena aplicada ao caso concreto ultrapassa dois anos, afastando a incidência do art. 77, do Código Penal.

Quanto ao tratamento dado à prisão preventiva, verifico que o réu respondeu à instrução processual custodiado e não há alterações de fato ou direito que justifiquem sua liberdade provisória. Assim, embasado no art. 312, do Código de Processo Penal, entendo estarem presentes os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar em vista à ordem pública.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

- a) ABSOLVER LÁZARO JOSÉ BENEDITO das imputações formuladas na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
- b) CONDENAR FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS como incurso no art. 33, caput, c.c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em valor mínimo-unitário. e ABSOLVÊ-LO pela prática do crime do art. 35, do mesmo Diploma Normativo.
- c) CONDENAR MARCOS HENRIQUE DE MEDEIROS CORREA como incurso no art. 33, caput, c.c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de

reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa em valor mínimo-unitário, bem como para ABSOLVÊ-LO pela prática do crime do art. 35, do mesmo Diploma Normativo;

d) CONDENAR ELTON WILLIAM MOREIRA como incurso no art. 33, caput, c.c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, às penas de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa, e ABSOLVÊ-LO pela prática do crime do art. 35, do mesmo Diploma Normativo.

a) Expeça-se alvará de soltura a LÁZARO JOSÉ BENEDITO, restituindo-lhe os valores apreendidos nos autos que lhe pertençam.

b) Custas pelos réus (art. 804 do CPP).

c) Expeçam-se as respectivas guias provisórias.

Após o trânsito em julgado:

a) Certifique-se nos autos o trânsito em julgado e atualize-se o Banco de Dados informatizado;

b) Expeça-se guia de execução definitiva (art. 105 da LEP);

c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III da CF/88 e art. 71, § 2º do Código Eleitoral);

d) Comunique-se ao órgão de identificação do Estado (art. 809 do CPP);

e) Nos termos do artigo 63 e §§ da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos;

f) Proceda-se na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Pindamonhangaba, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA